

1512988-87.2021.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... drogas para os adolescentes realizarem o tráfico no bairro. Diante dos fatos, o réu foi conduzido até a Delegacia, onde o Delegado de plantão ratificou a prisão de Gleison pelo tráfico de drogas. A denúncia foi formulada por um transeunte, que informou o intenso tráfico de drogas existente no bairro. Ele percebeu que um veículo VW/Santana parava diariamente junto a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1512988-87.2021.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512988-87.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2278279/2021 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 20779393 - 01º D.P. AMERICANA, 1643/21/344 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GLEISON CARLOS DA SILVA SIMPLICIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

GLEISON CARLOS DA SILVA SIMPLÍCIO foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, 'caput', da Lei 11.343/06, acusado de no dia 13 de outubro de 2021, por volta de 22h43, na Rua Camaquã, altura no numeral 100, esquina com a Avenida Tietê, bairro Vila Dainese, nesta cidade, transportar, para fins de traficância, 168 (cento e sessenta e oito) invólucros com a droga conhecida como crack, forma sólida da droga cocaína, pesando cerca de 44,9g (quarenta e quatro gramas e nove centigramas, substância esta causadora de dependência química, prontas para a venda e entrega ao consumo de terceiros, bem como R\$ 22,25, drogas essas que provocam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A denúncia foi instruída com Inquérito Policial.

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se defesa e acusação.

A denúncia foi recebida em 03/12/2021 (fls. 126/128) e o réu citado (fls. 153).

Na instrução foram inquiridas duas testemunhas comuns e uma testemunha de Defesa.

Ao final, o réu foi interrogado.

Sem mais requerimentos, nos debates, a acusação requereu a procedência da denúncia, alegando provados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre pena e regime.

A Defesa, em memoriais, alegou que as provas seriam insuficientes. O acusado seria usuário contumaz de entorpecentes e estava no local para adquirir drogas para o seu consumo, chegou inclusive a vender bens da casa para sustentar o vício. Os policiais militares ouvidos foram contraditórios e queriam induzir que a sacola com entorpecentes, encontrada distante do local da abordagem, fosse do acusado. Era pouco crível que o réu, ao conduzir um veículo Santana antigo, sem habilitação, conseguisse empreender fuga por dois quilômetros e arremessar um objeto dentro de um terreno baldio sem que fosse alcançado e abordado pelos policiais. Não havia provas da denúncia de abastecimento de drogas ou comercialização, não foi identificado nenhum possível comprador. Invoca o 'in dubio pro reo'.

Para o caso de condenação, pena mínima, pois a única anotação seria por infração ao artigo 28, da Lei de Drogas. Reconhecimento do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo, regime brando. Faria jus à substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, pugnando enfim pela aplicação da detração da pena e recurso em liberdade (fls. 168/180).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

Verifica-se dos autos que o réu foi preso em flagrante delito e na fase administrativa permaneceu em silêncio.

"Na real verdade, preso naquelas circunstâncias a que a tradição do direito chama 'certeza visual do crime' (cf. Tostes Malta, do flagrante delito, 1933, p. 25), e permanecendo calado na Polícia (fl.7), em vez de repelir, com a última força, a imputação, como fazem os inocentes, apenas o decreto condenatório poderia atender a um tempo à prova dos autos, à razão lógica e aos ditames da Justiça. Cai a lanço aquilo de Peter Thorton: 'A inocência pelo direito de falar; a culpa, essa invoca o privilégio do silêncio' (Justice on trial, p. 36; Revista da Escola Paulista da Magistratura, 2, p. 117). Impossível dizer melhor!" (TACRIM SP, 15ª C. - AP 1.286.483/3 - Rel. Carlos Biasotti, j. 07.02.2002, rolo-flash 1472/110).

"Embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal do inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência não se reservar para prestar esclarecimentos apenas em Juízo." (Ap. Crim. 1070141/5, Taubaté, Rel. Renato Nalini, TACRIM SP, j. em 20.10.1997).

"PROVA. Interrogatório policial. Silêncio do réu. Valor. O silêncio do réu, quando interrogado na fase policial, direito constitucional que lhe foi assegurado, é comprometedor, pois o inocente brada desde logo sua inocência e apresenta eventual alibi ou justificativa de seu ato." (TACRIM SP, AC 1.288.149/1, SP, 8ª Câmara, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 13.12.2001).

Em Juízo, alegou que no dia 12, por volta de 15 horas, estava em sua casa quando o seu pai o chamou para fazer uma mudança. Carregaram o caminhão no bairro onde moravam, Parque das Nações e levaram a mudança até a cidade de Campinas. Retornaram para casa por volta de 20h30. Seu pai lhe deu a quantia de R\$ 30,00. Pegou a sua bicicleta e foi até o bairro São Roque, onde comprou duas pedras de crack e dois maços de cigarros. Voltou para casa, foi até a área dos fundos do imóvel e passou a consumir a droga. Por volta de 21h30, acabaram as porções que havia comprado. Não estava satisfeito, queria usar mais. Foi até o quarto do seu pai e o chamou para pedir mais dinheiro. Seu genitor o repreendeu, disse que já tinha usado as "suas porcarias" e que não poderia sair após às 22 horas. Determinou que ficasse quieto em casa. Respondeu que ainda eram 21h30 e que após iria até o São Roque e não sairia mais. Seu genitor falou para pegar as chaves do caminhão para buscar os trocados que havia sobrado do pedágio, totalizando a importância de R\$ 20,25. Ao

buscar as chaves do caminhão, avistou também as chaves do carro e saiu com o veículo, sem que o seu pai percebesse. Ao se aproximar do bairro São Roque, deparou com uma viatura da Polícia Militar. Parou na sinalização de PARE e a viatura passou, fez o retorno e o seguiu. A equipe se aproximou e deu ordem de parada. Não era habilitado, por isso não parou. Pensou em voltar para casa, mas não teve chance. A viatura parou ao seu lado, o policial apontou a arma para a sua cabeça e o advertiu de que se não parasse, efetuariam um disparo contra a sua cabeça. Parou o carro e foi retirado bruscamente pelo policial de dentro do veículo. Foi jogado no chão e questionado se era foragido da Justiça e se possuía drogas ou armas dentro do carro. Respondeu que não era foragido e de que não tinha nada de ilícito em seu poder. Indagado sobre os motivos pelos quais desobedeceu a ordem de parada, respondeu que não era habilitado. Explicou ao policial que estava indo aquele horário até o bairro São Roque para comprar drogas. O policial o levantou do chão e disse que teria que levá-lo na bocada em que pegava drogas. Respondeu que não faria isso para não ser morto. O policial falou que como estava “passando o pano” para traficante, “iria se foder”. Seu veículo foi revistado e nada de ilícito foi encontrado. O policial mandou o colega voltar e procurar por drogas, acaso encontrasse entorpecentes, seria seu. Respondeu que não tinha nada e não jogou nenhum objeto.

O policial montou na viatura, desceu três quarteirões, na mesma rua, fez o retorno, nem desceu da viatura e retornou até o local da abordagem, com uma sacola de supermercado nas mãos e anunciou que encontrou drogas pendurada na cerca, lá embaixo. Foi algemado e colocado dentro do porta-malas da viatura. O policial anunciou que voltaria para a prisão por estar passando o pano para traficante e que se o levasse até o traficante, seria liberado. Havia dito que estava sem documentos por ter saído há pouco tempo da prisão. Argumentou que a droga não era sua e o policial mandou que provasse isso na Delegacia para ir embora.

A negativa do réu não convence.

A testemunha policial militar Júlio César Fugioka e Silva se recordou de que receberam denúncia que noticiava tráfico de drogas praticado por um homem que conduzia o veículo VW/Santana, de cor azul, no bairro São Roque. Ele entregava as drogas para a molecada fazer a venda. No dia 12 de outubro, por volta de 10h43, patrulhavam no Bairro Parque das Nações, quando cruzaram com o veículo VW/Santana, de cor azul, trafegando pela Rua Índia, cruzamento com a Rua Estados Unidos. Havia apenas o condutor no veículo, que possuía características convergentes com as descritas: homem magro e moreno. Ao avistar a viatura, o suspeito demonstrou nervosismo. Fizeram o retorno e tentaram a abordagem. O acusado acelerou o veículo. Deram ordem de parada com sirene e uso de luzes intermitentes, high light (luzes vermelhas). O suspeito simulou que iria parar e encostou o carro. Quando estava desembarcando da viatura, o réu acelerou novamente e fugiu pelas ruas do Bairro São Roque, por aproximadamente três ou quatro minutos. Na Rua Camaquã, o réu encostou para o lado esquerdo e arremessou um invólucro plástico. No local, havia uma cerca de arame farpado e o objeto ficou enroscado na cerca. Gleison prosseguiu em fuga e somente foi abordado cinquenta metros à frente, na Rua Tietê. O acusado parou o carro e realizaram a abordagem e busca veicular. Durante a revista, localizaram apenas dinheiro em poder do acusado. Algemaram o suspeito para evitar eventual fuga e retornaram até o local onde o objeto havia sido dispensado e encontraram drogas penduradas na cerca, embaladas de forma similar ao geladinho (biju). Contabilizaram seis kits de pedras de crack, contendo vinte e oito porções cada, totalizando 168 porções de crack. Indagado, o réu negou a propriedade dos entorpecentes.

Posteriormente, ele confessou informalmente que estaria nesse “corre errado” de tráfico de drogas, mas que apenas iria se manifestar em Juízo. Deram voz de prisão ao acusado, que foi conduzido com o veículo até a Central de Polícia Judiciária para providências de polícia judiciária. O entorpecente foi identificado como similar ao crack, fracionado e embalado em pequenas porções, prontas para a venda, contendo 28 porções em cada kit (acondicionado em saquinho de biju), totalizando 168 porções de crack, pesando cinquenta e poucas gramas, aproximadamente. A denúncia foi feita alguns dias antes, realizada por um popular que morava no

bairro. Ele noticiou que no seu bairro havia muito tráfico de drogas, praticado pelo condutor de um veículo VW/Santana, modelo antigo, de cor azul. O denunciante descreveu o suspeito como um homem moreno e magro. Patrulhavam nas imediações atentos ao veículo e que lograram em encontrar na ocasião dos fatos. Não possuía a qualificação do denunciante. Gleison não era conhecido da equipe e nem especificamente o veículo que conduzia. O veículo era de propriedade do genitor do acusado, que teve o carro liberado. Gleison permaneceu em fuga por aproximadamente quatro ou cinco minutos, ele andou por várias ruas do bairro. Acreditava que ele percorreu de um quilômetro e meio a dois quilômetros de distância. A viatura ficou bem próxima do carro que o réu conduzia, pois o carro apresentava algumas falhas, não apresentava plenas condições mecânicas. O réu não parou o veículo totalmente, ele foi encostando e arremessou o objeto, posteriormente identificado como kits de drogas. Pelo procedimento operacional padrão, não entram na frente de outro veículo, pois o suspeito pode estar armado e disparar nas costas do policial. A abordagem é sempre feita por trás do veículo. Efetuam o sinal de parada. Após o atendimento da ordem, desembarcam da viatura e determinam que o condutor saia do veículo com as mãos na cabeça e se dirija até a parte de trás do carro, oportunidade em que vistoriam o carro para averiguar se há mais infratores dentro do veículo que coloquem em risco a vida do policial. Em seguida, prosseguem na revista pessoal do suspeito para averiguar se ele está armado e posteriormente realizaram a busca veicular. Realizaram a abordagem e o protocolo de segurança da polícia militar em aproximadamente cinco ou seis minutos até retornarem no local onde as drogas foram localizadas. Não havia casas ou pessoas naquele local. Não sabia o nome do denunciante ou onde ele morava.

Ele não foi qualificado para preservar o seu anonimato e a sua segurança. O policial Ivan não estava em sua companhia no momento em que recebeu a denúncia. Ivan Rodrigues dos Reis, outro policial, ratificou a versão em uníssono, harmônica e coerentemente. Destacou que estavam em patrulhamento pelo bairro São Roque, populares informaram que o veículo VW/Santana, de cor escura, todas as noites, entre 20 horas e 22 horas, passava distribuindo kits de drogas para os adolescentes que efetuavam o tráfico no bairro. Ao passarem pela Avenida Estados Unidos, visualizaram o carro VW/Santana, na cor azul. O condutor, ao avistar a viatura, virou repentinamente na Rua Índia. Ante a fundada suspeita, tentaram a abordagem. Deram sinais de parada por meio de sinais sonoros e luminosos, que não foram respeitados. O suspeito empreendeu maior velocidade no veículo, trafegando pelas ruas do bairro. Em determinado momento, ao passar pela Rua Camaquã, o condutor do veículo arremessou uma sacola plástica em um terreno baldio. A sacola plástica ficou pendurada no arame fardado ali existente. O suspeito parou o carro cinquenta metros à frente. Realizaram a abordagem. Em revista, localizaram a quantia de R\$ 22,25. Ao ser questionado sobre o que havia arremessado, o acusado inicialmente negou os fatos. Foi necessário o uso de algemas, ante a desobediência e tentativa de evasão da equipe. Retornaram até o local onde estava a sacola, pendurada no arame fardado. Em seu interior, apreenderam seis kits com vinte e oito pedras em cada kit, totalizando 168 pedras de substância que aparentava ser crack. Em nova entrevista, Gleison informou que estava desempregado e que entregava drogas para os adolescentes realizarem o tráfico no bairro. Diante dos fatos, o réu foi conduzido até a Delegacia, onde o Delegado de plantão ratificou a prisão de Gleison pelo tráfico de drogas. A denúncia foi formulada por um transeunte, que informou o intenso tráfico de drogas existente no bairro. Ele percebeu que um veículo VW/Santana parava diariamente junto a molecada, que por sua vez pegava alguma coisa com o condutor. Em seguida, os moleques ficavam nas esquinas e constantemente outras pessoas ali paravam para comprar drogas. A denúncia foi feita no mesmo bairro em que houve a abordagem, poucas horas antes da prisão. O réu se esquivou da abordagem por aproximadamente dez minutos.

Ele procurou um local que elegeu como sendo melhor para dispensar os entorpecentes, em um terreno baldio, área de mato. Para a sua infelicidade, a sacola enroscou no arame fardado. O veículo conduzido pelo acusado não estava em boas condições, por esse motivo não o perderam de vista e mantiveram a proximidade durante a perseguição. O réu arremessou o objeto com o veículo ainda em movimento, apenas

reduziu um pouco a velocidade antes de arremessar. Não conheciam o acusado, trabalhavam em outro setor. Estava apenas em companhia do policial Fugioka. A testemunha de Defesa, Luiz Carlos Simplício, pai do acusado, alegou que o filho morava em sua casa, era usuário de drogas (maconha e cocaína). Não presenciou os fatos. Compareceu na Delegacia posteriormente para buscar o seu veículo, VW/Santana. Gleison usava o carro sempre que descuidavam. Na data, Gleison usou o carro escondido. Levava o seu filho em um laboratório, na cidade de São José do Rio Preto, para ser submetido a tratamento pela dependência química, mas ele nunca foi internado. A aplicação da medicação injetável não teve resultado definitivo. Notou que Gleison ficava alguns dias sem ansiedade e parava de pedir "essas coisas". As aplicações de medicamentos eram quinzenais ou mensais. Quando Gleison foi preso, ele o ajudava a transportar com o caminhão. Desconhecia que o seu filho tivesse algum envolvimento na venda de entorpecentes ou outras coisas. Sabia apenas que Gleison usava drogas, inclusive ele já furtou objetos do lar. 'Se sobrava na reta', ele pegava as coisas para sustentar o seu vício. Não há como prestigiar a versão do réu, pois, em detrimento do seguro depoimento de policial militar.

Sequer o pai do réu ousou confirmar a versão dele, de autorização de uso do veículo ou entrega de dinheiro para a compra de droga para uso. Ao contrário, o genitor foi sincero em revelar que o filho tinha mesmo envolvimento com drogas, a família se preocupava e tentava tratamento, mas na mínima hesitação o réu saía com o carro e também subtraía até a própria casa para comprar drogas.

Quanto aos policiais, sabiam eles, por informação valiosa de transeunte inconformado com o vistoso tráfico cometido por adolescentes (molecada), após recebimento de drogas por homem que descreveram (que correspondia ao réu), com veículo com as características do ocupado pelo pai, no bairro.

Assim é que, na noite, o réu foi visto algumas horas depois do recebimento dessa notícia e malgrado a péssima condição do carro, tentou fuga. Impossibilitado, tentou se desfazer da droga que levava, expressiva e em kits.

Finalmente abordado, nada levava no carro, mas o embrulho dispensado, sacola, ficou pendurado na cerca e revelou que o réu jogou vários (6) kits de entorpecentes, mais de 50 gramas, somando 168 pedras de crack.

Os policiais apresentaram versões firmes e coerentes, todas revelando que o réu foi mesmo quem dispensou tanto expressivo de droga. Também levava dinheiro, sem procedência lícita provada.

As circunstâncias da prisão em local já conhecido como ponto de tráfico; a denúncia com descrição do veículo e do acusado, a apreensão das drogas, já embaladas em pequenas porções, prontas para a venda e entrega ao consumo de terceiros; tentativa de fuga do acusado, que foi imediatamente perseguido e detido pelos policiais militares, com suspeitosa dispensa de sacola, evidenciam que ele vinha se dedicando a essa atividade criminosa.

A conduta é mesmo a de tráfico, não sendo necessário, para a hipótese, que o réu estivesse vendendo drogas. A acusação é pontual em alegar que ele transportava, drogas para a mercancia.

Trata-se de crime de ação múltipla e conteúdo variado, não carecendo a prática de atos de mercancia para a configuração do tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Agente que não comercializou a droga - Caracterização pela simples guarda, pois o tipo do art. 12 da Lei 6.368/76 é de conteúdo variado ou misto alternativo" (TJRS, RT 745/633).

E, por pertinente: "ENTORPECENTE - Tráfico - Caracterização - Crime de perigo abstrato - Desnecessidade da prática de efetivo ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito a

substância entorpecente, para finalidade de venda. Inteligência do art. 12, caput, da Lei 6.368/76" (TJSP, RT 793/576).

Indiferente a alegação do réu, assim, de que não teria envolvimento com o tráfico, na conduta de vender o entorpecente, ainda que desmentida pelos policiais militares, na medida em que a acusação é certa de imputar a ele a conduta de transportar, para esse fim, que poderia por evidente (a venda) ser realizada por terceira pessoa, que não identificou.

A prova, enfim, é boa e suficiente, com prisão em flagrante delito, certeza visual do delito, apreensão da droga e depoimentos de policiais.

Não há de se colocar ressalvas no depoimento de policiais militares tão só por essa condição.

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (HC no. 5J.577; DJU 7.12.73, p. 9.372; apud Damásio E. de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, 22a. ed., p. 187).

"Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após foram compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tudo por vil escopo de inculpar inocente" (RT 411/266; no mesmo sentido, STF, HC 73.518-SP, Rel. Ministro Celso de Mello).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF, HC 74.608 SP., Rel. Min. Celso de Mello).

Merece transcrita a lição do Des. ARY BELFORT: "A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia - há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de, coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP vol. 136, pág. 477).

Sequer fez prova da versão exculpatória, como lhe incumbia.

Como ensina Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, "O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o álibi constitui um a exceção de defesa e, como tal, cabe ao incriminado o ônus de sua demonstração" (Da prova no processo Penal, editora Saraiva, 7ª ed. 2006, p.18).

O STF já teve oportunidade de decidir nesse sentido, no HC 68.964-7-SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU 22.04.1994, cuja ementa tem o seguinte teor:

"O álibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita".

A respeito, já se decidiu que "de acordo com a jurisprudência do STJ a defesa deve comprovar o álibi apresentado." (STJ, 5ª Turma, Habeas Corpus nº 44.376/SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 17.11.2005).

Também o fato de ser usuário de drogas não afasta a traficância, quando o porte de eventual droga é absorvido pelo crime de maior severidade, no caso, o tráfico.

Inclusive, é rotineira a alegação de mero uso, antes evidenciando o propósito desmedido de usuários, para satisfação de vício, dignarem-se a transportar drogas ou até procederem a venda, com retenção de parte (como paga) para consumo. Não é improvável que o réu assim tivesse agido, o que é indiferente pela prova segura de que transportava droga alentada para esse fim, sem que possuísse mesmo meios para aquisição de droga naquele tanto (168 pedras), pois até a própria casa ousava furtar, assim como se apossar desautorizadamente do veículo do pai para delinquir. A alegação de necessidade, em sua versão, de todo o modo não lhe dá direito ou permissão para trazer com ele e ter em depósito drogas, para o grave crime de

tráfico.

Por evidente, o princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, crime de perigo abstrato e em que é irrelevante a quantidade da substância apreendida (neste sentido, 5ª T. STJ, Rel. Min. Jorge Mussi, REsp 1.637.113).

A materialidade da infração foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), pelo laudo de constatação (fls. 13/15), e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 63/65).

Bem típica a conduta, pois, que merece severa punição.

Fixação das penas.

O réu é tecnicamente primário, pois a condenação no Processo nº 0002252-84.2018.8.26.0344, da 1ª Vara Criminal do Foro de Marília pelo artigo 28, "caput" do SISNAD (fls. 39) é inábil para a reincidência (PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. AGRAVANTE AFASTADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (AgRg no HC 602.724/SP, 5ª T. Rel. ministro Ribeiro Dantas). Fixo a pena base no mínimo legal. Na segunda, não há circunstância a ser considerada, repetido que a condenação no Processo nº 0002252-84.2018.8.26.0344 pelo artigo 28, "caput" do SISNAD não gera reincidência. Mantenho inalterada a pena base.

Na terceira e última fase, sem comprovação de que se dedicasse a atividade criminosa e nem integrasse organização criminosa, reduzo a pena em metade, assim a tornando definitiva, justificando-se o percentual pela nocividade da droga (crack) e as circunstâncias que nortearam a infração.

É de se impor o regime inicial aberto, pela somatória da pena, reclusiva.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o disposto no artigo 33, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal.

Depois, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o entendimento de que: "Esta Corte, na esteira do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, entende ser possível nas condenações por tráfico de drogas, em tese, a fixação de regime menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sempre tendo em conta as particularidades do caso concreto." HC nº 239.999/MS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21.08.2014.

Na mesma evolução, com a promulgação da Lei nº 13.964/2019 (popularmente conhecida como "pacote anticrime"), houve necessidade de maior reflexão pelos julgadores. Dentre as alterações previstas no regime legal, houve alteração expressa da Lei de Execuções Penais, em especial no tocante ao "tráfico privilegiado": Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). (...) § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu para condenar a GLEISON CARLOS DA SILVA SIMPLÍCIO, às penas de dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão, regime inicial aberto e duzentos e cinquenta (250) dias-multa, piso mínimo da Lei de drogas, por infração ao artigo 33, 'caput' e parágrafo 4º, ambos da Lei número 11.343/2006.

Presentes os pressupostos legais, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena e mais prestação pecuniária, que arbitro em um (01) salário-mínimo. Não há valor mínimo indenizatório a ser arbitrado.

Isento o réu das custas, assistido por defensor nomeado e presumida a necessidade (fls. 48).

Vinculado o numerário apreendido com o crime cometido, decreto a sua perda em favor da União, bem como os objetos apreendidos, ficando autorizado, quanto a estes últimos, doação ou destruição, acaso inservíveis ou sem valor econômico, o que será

certificado.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Preso pelo processo, expeça-se alvará de soltura, incompatível a substituição ora operada com a prisão vigente. Faculto recurso em liberdade.

Após o trânsito, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Americana, 15 de fevereiro de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA